

1501119-46.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501119-46.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501119-46.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102224/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO

PLANTÃO, 11112717 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2894/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO

PLANTÃO, 2102224 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2894/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

2102224 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2894/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGO BUENO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

RAFAEL RODRIGO BUENO DOS SANTOS, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 19h15min, na Rua 14, nº 3896, Vila Olinda, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, vendeu 04 (quatro) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, trazia consigo 01 (um) microtubo do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente denominada cocaína, e ainda guardava e tinha em depósito outros 05 (cinco) microtubos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente

denominada cocaína, totalizando com aqueles outros peso líquido aproximado de 2 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação de fls. 18/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 72/73).

Regularmente notificado (fls. 100), seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do Acusado (fls. 104/105), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 22 de outubro de 2020 (fls. 111/114).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 172/173), seguindo-se o interrogatório do acusado (fls. 172/173).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a aplicação do redutor, com fixação de regime prisional inicial fechado, além de se declarar o perdimento da quantia em dinheiro com ele apreendida, já que decorria do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 172/173 e 222).

Já ilustre Defensora Pública inicialmente pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, dada a diminuta quantidade de entorpecente apreendida, com a consequente absolvição, tudo nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sustentou, ademais, estar a prova da materialidade delitiva prejudicada, já que originada de apreensão ilícita do entorpecente, uma vez que realizada por Guardas Civis Municipais, os quais não possuem atribuições para realizar diligências como aquelas efetuadas na ocasião, configurando atuação ilícita, a ensejar a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, sustentou insuficiente a prova produzida, requerendo a absolvição do acusado, aqui nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, pugnou pela desclassificação do delito atribuído inicialmente ao Acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, fixando-se a pena aquém do mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto ou regime prisional diverso do fechado, caso não seja aplicado o redutor, e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 172/173 e 222).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, comercializou e trazia consigo e ainda guardava e tinha em depósito o entorpecente descrito na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontestada, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de constatação de fls. 18/20, relatório de análise de fls. 82/83 e laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 80/81, com resultado positivo para cocaína.

Sustenta-se prejudicada a materialidade delitiva, diante das diligências realizadas, já que a Guarda Civil Municipal não reuniria atribuições para a abordagem, à vista do disposto no artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Entretanto, consta que Guardas Civis Municipais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o Acusado e Juliana, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que ele passou a ela de maneira discreta e suspeita um objeto em circunstância que indicava o estado flagrancial, autorizando a abordagem (cf. art. 301, CPP), o que resultou efetivamente na apreensão de entorpecentes.

Não se ignora a controvérsia que marca os limites da ação da Guarda Municipal, importante estrutura que atua nos Municípios em proveito da segurança pública, notadamente em ambiente de intensa criminalidade.

Não por outro motivo se editou a Lei n. 13.044/2014 com o objetivo de regulamentar

a extensão do disposto no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, de modo a incorporá-la ao sistema de atuação dos organismos que atuam em favor da segurança pública, embora objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que não se entrevê por aqui em caráter incidental.

E a situação, no caso, dentro das competências estabelecidas pela referida Lei Federal, diante do comportamento do Acusado, que passava um objeto para terceira pessoa, de maneira suspeita, em local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecente, decorre da experiência comum, do id quod plerumque accidit, que tal comportamento se ajusta a ocorrência de empreita delitiva, evidenciando estado flagrancial, a autorizar a abordagem, seguida da busca pessoal, que resultou efetivamente na apreensão do entorpecente.

A propósito: HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] (HC 421.954/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) Grifos Nossos. Assim, fica afastada a alegação de ter restado comprometida a materialidade delitiva.

E não se mostra possível a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, em razão do maior potencial lesivo da substância (cocaína) e, ainda, porque se cuida de crime de perigo abstrato, não obstando a tipificação do delito a menor quantidade de entorpecente apreendida.

Sobre isto: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2.Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.163/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe08/10/2021)" Grifos nossos.

Controverte-se sobre a posse da totalidade do entorpecente apreendido bem como a destinação mercantil.

Ouvido em juízo, o Acusado negou o tráfico de entorpecentes. Relatou que, por ocasião dos fatos, quando em companhia de Juliana, com quem mantinha relação amorosa, foram adquiridas as substâncias ilícitas para consumirem em conjunto. Informou que não possuía qualquer quantia em dinheiro naquela oportunidade, sendo que os valores apreendidos pertenciam à companheira. Acrescentou que, após comprarem cocaína, pararam em um ponto de ônibus para fazerem o uso, sendo que a substância estava acondicionada em seis eppendorfs de cor amarela, que eram inclusive diferentes daqueles de cor verde, os quais foram apreendidos pelos Guardas Civis, nas imediações. Por fim, afirmou que Juliana relatou estes fatos para a d. Autoridade Policial (fls. 172/173).

Todavia, a versão deduzida pelo Acusado, foi contrariada pela prova produzida. Conquanto somente na fase inquisitória, já que não mais localizada, a testemunha Juliana declarou que era usuária de entorpecentes e que, na data dos fatos, teria adquirido cocaína do Acusado pelo valor de quarenta reais, quando então foram abordados pelos Guardas Civis (fls. 07).

Reiterando em Juízo o que exposto contemporaneamente aos fatos, os Guardas Civis

Municipais, Marcos Ricardo e Valderi, afirmaram que estavam em patrulhamento defronte a um ponto de ônibus -- local conhecido por intensa ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes --, quando observaram o momento em que o Acusado passou, de maneira discreta e suspeita, um objeto a Juliana. Em razão daquela movimentação realizaram a abordagem e apreenderam em poder de ambos o entorpecente, sendo que Juliana confirmou que havia comprado do Acusado, com quem localizada quantia em dinheiro. Acrescentaram que foi realizada diligência, nas proximidades, onde efetivamente foi apreendida outra quantidade de entorpecente, que continha as mesmas características daquele anteriormente encontrado com o casal. Informaram que o Acusado admitiu a mercancia ilícita (fls. 172/173).

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos Guardas Civis Municipais envolvidos na diligência.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, os elementos probatórios produzidos permitem seguro juízo de convicção sobre a posse do entorpecente, bem como sobre sua destinação mercantil, em razão das circunstâncias relacionadas à apreensão (local de venda, informação da usuária de entorpecentes e confissão informal), ficando afastado, portanto, o reclamo de desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Por fim, considerando que os valores apreendidos estavam em poder do Autuado, sendo que a testemunha indicou que teria efetuado pagamento a ele, possível concluir que decorria da atividade ilícita, a fazer incidir a pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, a despeito do registro criminal ostentado, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância atenuante da menoridade, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Por fim, em face da primariedade, não integrando o Acusado organização criminosa e não havendo elementos que indiquem estivesse dedicado ao comércio ilícito, a despeito do registro criminal ostentado, deve pena-base cominada ser reduzida em 2/3 (dois terços), em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do Acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo. Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes.

No entanto, a fim de se observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolatação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado RAFAEL RODRIGO BUENO DOS SANTOS à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA